

是否已形成经济利益为标准，存在潜在商业价值的也可认定。如已达成合作意向、签订备忘录或签订了合同，因侵权人的行为导致权利人未能继续履约，可以认定该客户信息具有商业价值。本案中，案涉客户信息是某体育器材公司在公共信息的基础上搜集、整理、挑选，并通过实地访问、谈判磋商、关系维护而逐渐形成，付出了创造性的劳动，也耗费了一定的人力、物力和财力。这些客户信息具有独特的商业价值，客观上也为某体育器材公司带来了经济利益。根据专项审计报告，王某在职期间，某2公司等共计为某体育器材公司带来219万余元利润，具有较大的经济价值。

最后，关于保密性要件，即权利人是否采取了相应保密措施。《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第六条规定了认定权利人采取了相应保密措施的七种情形。司法实践中，一般从三个方面进行考量：(1)是否足以使竞争对手通过正当手段无法获取；(2)是否足以使保密义务人清楚权利人具有保密的主观愿望，清楚自己的保密义务和保密对象；

(3)权利人采取的保密措施是否与客户信息的商业价值相适应。本案中，某体育器材公司对涉案客户信息采取了多形式的保密措施，如对客户进行编码并存放于保险柜，实行字母代号流转、客户信息分级管理、员工手册及保密协议中明确约定商业秘密的经营信息范围及离职时需删除相关信息等。结合王某从事的外贸员工作岗位及其工作经验，足以认定王某主观上对于涉案客户信息系某体育器材公司重要信息以及某体育器材公司针对该信息具有较强的保密意愿、并采取了

必要和适当的保密措施均系明知，该事实也与王某供述 相印证

。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 陆炜炜
南通通州湾江海联动开发示范区人民法院 陶书林

(八) 扰乱市场秩序罪

56

录制夸大、失实保健品宣传视频，并指导经销商 采用会销形式吸引老年人购买的行为构成虚假广告罪

—— 何某等虚假广告案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省日照市岚山区人民法院(2023)鲁1103刑初240号刑事判决书

2. 案由：虚假广告罪

【基本案情】

2020年下半年，被告人何某找被告人吴某某商议合作成立公司销售保健品，二人确定以会销方式销售某胶囊。

2020年11月，何某注册成立某商贸有限公司并负责公司运营、招商销售，吴某某担任宣传视频讲师，何某分得公司利润的40%，吴某某分得60%。后何某又找来被告人唐某某从事产品招商销售，承诺拿出自己的部分利润给唐某某。吴某某另外还抽取公司销售某胶囊回款额的6%作为讲师提成。

2021年年初，吴某某录制了含有虚假、夸大某胶囊产品背景、功效等内容的宣传视频。被告人高某某根据吴某某录制的视频形成相对对应的话术、培训资料、宣传资料。被告人高某某、杨某、秦某等督导组工作人员根据公司安排给

经销商发送宣传视频和话术、培训资料等，并具体指导经销商销售，最终由门店经销商给到店老年人播放宣传视频并配合宣传话术、试吃活动，吸引老年人购买。被告人何某等人进购某胶囊的价格为130元一套，加上赠品成本共计405元至455元，以700元至800元不等的价格向下级经销商销售近3万套，并确定门店销售价格为2800元一套。

被告人秦某共计指导销售某胶囊至少774套；被告人杨某共计指导销售某胶囊至少396套。被告人吴某某分得讲师提成1695637.86元、公司利润300万元，被告人何某分得公司利润125万元，被告人唐某某分得公司利润65万元。被告人高某某非法获利6万元，被告人秦某非法获利4万元，被告人杨某非法获利3万元。案发后，各被告人均已退缴违法所得，被告人吴某某取得部分老年人谅解。

【案件焦点】

录制夸大、失实保健品背景及功效的宣传视频，授意安排、培训指导下级经销商利用该视频，并采用会销形式吸引老年人购买保健品的行为如何定性。

【法院裁判要旨】

山东省日照市岚山区人民法院经审理认为：被告人何某、吴某某、唐某某、高某某、秦某、杨某违反国家规定，利用广告对销售商品作虚假宣传，情节严重，侵犯了广告市场管理秩序和不特定消费者的合法权益，应以虚假广告罪追究刑事责任。被告人何某、吴某某、唐某某、高某某构成自首，被告人秦某、杨某具有坦白情节，依法均可以从轻处罚。被告人高某某、秦某、杨某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人唐某某、秦某、杨某认罪认罚，依法可以从宽处理。各被告人均已退缴违法所得，被告人吴某某取得部分老年人谅解，均可酌情从轻处罚。据此，山东省日照市岚山区人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十二条，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条之规

定，作出如下判决：

一、被告人何某犯虚假广告罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币40万元；

二、被告人吴某某犯虚假广告罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币80万元；

三、被告人唐某某犯虚假广告罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15万元；

四、被告人高某某犯虚假广告罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币2万元；

五、被告人秦某犯虚假广告罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元；

六、被告人杨某犯虚假广告罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定，违反国家规定，利用广告对保健食品或者其他食品作虚假宣传，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十二条规定的，以虚假广告罪定罪处罚；以非法占有为目的，利用销售保健食品或者其他食品诈骗财物，符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的，以诈骗罪定罪处罚。本案处理的重点在于被告人罪名认定的问题，该行为系构成诈骗罪还是虚假广告罪。

个别不法商家为了营利不择手段，尤其是保健品销售领域问题较为突出。本案中，被告人何某等人通过制定营销模式、录制宣传视频，将不具有防病、治病功能的保健品吹嘘成能够治

疗癌症、肿瘤、心脑血管疾病、帕金森、脑梗、 疝气等疾病的
产品销售给老年人。本案存在如下观点。

第一种观点认为构成诈骗罪。理由是：何某等被告人通过录制虚构产品功

